Universität St.Gallen

Prüfungsbooklet Assessment

Rechtswissenschaft I B

Teil Schindler

Hinweise:

- **Die alten Prüfungen dienen als Lernhilfe.**
- **Die Musterlösungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.**
- **Die zitierten Stellen des Lehrbuchs oder die angegebenen Folien beziehen sich auf die zum Prüfungszeitpunkt aktuelle Auflage bzw. aktuelle Vorlesungsstruktur.**

Prüfung Assessment-Jahr - Sommer 2020

Teil Prof. Schindler

Name: | **Vorname:**

Muttersprache(n): Matrikel-Nr.:

Prüfungsfach: **Rechtswissenschaft I B (schriftliche Prüfung)**

2.170

Prüfungsteil: **Prof. Dr. B. Schindler (90 Minuten)**

Verantwortlich: Prof. Dr. S. G. Schmid

Bemerkungen:

Die Prüfung umfasst **4 Aufgaben auf 13 Seiten** (inkl. diesem Deckblatt). Die Punkte verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen Aufgaben:

1. Aufgabe	29 Punkte
2. Aufgabe	23 Punkte
3. Aufgabe	21 Punkte
4. Aufgabe	17 Punkte
Total	**90 Punkte**

Wichtig: Vergessen Sie jeweils nicht die Nennung der entsprechenden Rechtsnormen! Begründen Sie jede Antwort!
Bitte lösen Sie die Aufgaben direkt auf dem Aufgabenblatt.

Aufgabe 1 — 29 Punkte

Der Sachverhalt ist frei erfunden!

Nationalrätin Eleonore Stuss aus dem Kanton Neuenburg arbeitet neben ihrem Nationalratsmandat auch in der Privatwirtschaft. Aufgrund der COVID-19-Krise hatte das Unternehmen, das Frau Stuss beschäftigt, im März 2020 jedoch nur sehr wenige Aufträge, sodass Frau Stuss nicht sehr viel zu tun hatte. Sie ergriff die Gelegenheit beim Schopf und unternahm in ihrer zusätzlichen Freizeit im März eine Wanderung im Alpstein im Kanton Appenzell Innerrhoden. Dabei stürzte sie jedoch und verletzte sich am Knie. Frau Stuss musste sich in einem lokalen Spital einer Operation unterziehen. Das staatliche Spital, in dem die Behandlung stattfand, passte Frau Stuss jedoch gar nicht. Insbesondere fand sie die Infrastruktur im Spital völlig veraltet und nicht zweckmässig. Frau Stuss gefällt es gar nicht, dass in der Schweiz noch solche Spitäler betrieben werden. Als sie nach der Behandlung wieder in ihrem Heimatkanton Neuenburg eintrifft, kommt ihr sofort die Idee, dass sie einen Vorstoss dazu im Nationalrat einreichen könnte. Der Bund solle den Kantonen künftig vorschreiben, wie alt die kantonale Spital-Infrastruktur höchstens sein darf. Um Vorstösse zu besprechen, wendet sich Frau Stuss regelmässig an Sie als Ihr Rechtsberater bzw. Ihre Rechtsberaterin. Auch in dieser Sache stellt Ihnen Frau Stuss folgende Frage:

Frage 1: [10 Punkte]
Äussern Sie sich zunächst allgemein zur Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen. Beurteilen Sie anschliessend, ob Frau Stuss' Vorstoss mit der geltenden verfassungsmässigen Kompetenzordnung vereinbar wäre.

Nach dem Grundsatz der Einzelermächtigung des Bundes durch die Bundesverfassung (Art. 42 BV) (**1 Punkt**) ist der Bund nur zuständig, soweit die Bundesverfassung dem Bund eine Kompetenz ausdrücklich zuweist (**1 Punkt**). Ansonsten bleiben aufgrund ihrer subsidiären Generalkompetenz (Art. 3 BV) die Kantone zuständig (**1 Punkt**). Dies entspricht auch dem Gedanken der Subsidiarität, der in Art. 5*a* BV festgehalten ist; er ist aber nur eine «politische Klugheitsregel» und vermag die realen Kompetenzen nicht zu beeinflussen.

Vorliegend geht es um eine Frage der Gesundheitspolitik (**1 Punkt**). Trotz der weitgefassten Sachüberschriften von Art. 117*a* und Art. 118 BV besitzt der Bund im Bereich der Gesundheitspolitik nur punktuelle Kompetenzen; im Wesentlichen sind die Kantone zuständig (**1 Punkt**). Sowohl Art. 117*a* Abs. 1 BV als auch Art. 118 Abs. 1 BV begründen eine fragmentarische Bundeskompetenz, die in den darauffolgenden Absätzen konkretisiert wird (**2 Punkte**). Im Rahmen der in Art. 117*a* Abs. 2 bzw. Art. 118 Abs. 2 BV abschliessend aufgezählten Bereiche verfügt der Bund über eine umfassende Bundeskompetenz (**1 Punkt**). Darunter findet sich aber keine

Bundeskompetenz, die dem Bund so weitgehende Eingriffe in das kantonale Spitalwesen erlauben würde, wie sie Frau Stuss verlangt (**1 Punkt**). Frau Stuss' Vorstoss ist deshalb nicht mit der verfassungsmässigen Kompetenzordnung vereinbar (**1 Punkt, Fazit**).

Frage 2: [5 Punkte]
Frau Stuss setzt sich im Rahmen ihrer parlamentarischen Tätigkeit auch stark für den Schutz des Klimas ein. Die Monate März und April 2020 waren in der Schweiz sehr trocken, was gemäss Frau Stuss «klarerweise auf den Klimawandel zurückzuführen» sei. Wegen der COVID-19-Krise habe man den Klimaschutz zu vernachlässigen begonnen, glaubt Frau Stuss. Es sei viel zu wenig über die Trockenheit berichtet worden in den Medien. Frau Stuss möchte auch im Bereich des Klimaschutzes einen Vorstoss im Nationalrat einreichen und fragt Sie im Vorfeld, ob Art. 74 BV eine Bundeskompetenz begründe, und falls ja, wie sie zu qualifizieren wäre.

Art. 74 Abs. 1 BV begründet eine Bundeskompetenz (**1 Punkt**). Darauf deuten der Wortlaut der Bestimmung und ihre Stellung in der BV hin (**1 Punkt**). Betreffend Umfang handelt es sich um eine umfassende Rechtsetzungskompetenz, wie sich aus dem Wortlaut ergibt («Der Bund erlässt Vorschriften über...») (**1 Punkt**). Die Wirkung ist nachträglich derogatorisch, was dem Normalfall entspricht (**1 Punkt**).

Die in Art. 74 Abs. 3 BV zum Ausdruck gelangende Vollzugsregelung entspricht der Grundnorm von Art. 46 Abs. 1 BV (**1 Punkt**). Bereits die (umfassende) Rechtsetzungskompetenz von Art. 74 Abs. 1 BV befähigt den Bund, die Zuständigkeit zum Vollzug selbst festzulegen, womit Art. 74 Abs. 3 BV an sich überflüssig ist (**1 Zusatzpunkt**).

Frage 3: [12 Punkte]
Frau Stuss fragt Sie, ob der Bund Massnahmen gegen den Klimawandel, der ja die ganze Schweiz betrifft, nicht auch direkt auf Art. 43*a* Abs. 1 BV stützen könnte? Gehen Sie allgemein auf das Subsidiaritätsprinzip ein und beantworten Sie Frau Stuss' Frage.

Der Grundsatz der Subsidiarität nach Art. 5*a* BV ist Leitlinie für die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen (**2 Punkte**). Dem Bund sollen nur jene Aufgaben zugewiesen werden, welche die Kraft der Kantone übersteigen oder einer gesamtschweizerischen Regelung bedürfen (Art. 43*a* Abs. 1 BV) (**1.5 Punkte**).

Auch bei der Ausübung einer Bundeskompetenz ist der Grundsatz der Subsidiarität zu beachten (**1 Punkt**). Der Bund soll seine Kompetenzen nur so weit wie nötig in Anspruch nehmen; er soll den Kantonen ausreichend eigene Aufgaben sowie die dafür erforderlichen Finanzierungsquellen belassen (Art. 47 BV).

Hintergrund des Subsidiaritätsprinzips ist der Gedanke, dass die obere Einheit eines Ganzen nicht Aufgaben an sich ziehen soll, welche die untere Einheit als kleinere Gemeinschaft ebenso gut erfüllen könnte (Staatsaufbau von unten nach oben) (**1 Punkt**).

Nach dem Gesagten betrifft das Subsidiaritätsprinzip das Verhältnis der verschiedenen Staatsebenen untereinander und nicht dasjenige zwischen Staat und Gesellschaft (**1 Punkt**).

Beim Subsidiaritätsprinzip handelt es sich um eine politische Maxime («Klugheitsregel»), die sich an den Verfassungs- und Gesetzgeber richtet (**1 Punkt**). Es kommt ihm aber keine Justiziabilität zu (**1 Punkt**). Mit anderen Worten lässt es sich nicht gerichtlich durchsetzen und es bleibt primär eine politische Frage, ob und wie der Maxime tatsächlich gefolgt wird.

Beantwortung der Frage von Frau Stuss
Art. 43*a* Abs. 1 BV begründet aufgrund seines allgemeinen und programmatischen Charakters keine Bundeskompetenz (**1 Punkt**). Allerdings gebietet der Grundsatz der Subsidiarität, dass der Bund seine Kompetenz im Bereich des Umweltschutzes möglichst «schonend» ausübt und den Kantonen (wo sinnvoll) einen eigenen Spielraum belässt (**1 Punkt**).
Fazit: Der Bund kann Massnahmen gegen den Klimawandel somit nicht direkt auf Art. 43*a* Abs. 1 BV stützen, auch wenn der Klimawandel tatsächlich die ganze Schweiz betrifft (**1.5 Punkte**).

Frage 4: [2 Punkte]
Legen Sie dar, ob Art. 185 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 BV eine Bundeskompetenz begründet!

Bei Art. 185 Abs. 2 in Verbindung mit 3 BV handelt es sich um keine Verbands-, sondern um eine *Organkompetenz* (**1 Punkt**), welche die Zuständigkeit des Bundesrats festlegt, um Massnahmen zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit zu treffen. Ein Indiz hierfür ist auch die systematische Stellung der Norm innerhalb der BV; sie befindet sich im 5. und nicht im 3. Titel, in dem meist die Verbandskompetenzen geregelt sind (**1 Punkt**). Allerdings gibt es Stimmen in der Lehre, gemäss denen der Bundesrat mit auf Art. 185 Abs. 3 BV gestützten Verordnungen in die verfassungsmässige Kompetenzordnung eingreifen kann (**1 Zusatzpunkt**) oder die Wahrung der Sicherheit als implizite Bundeskompetenz betrachten (**1 Zusatzpunkt**).

Aufgabe 2 — 23 Punkte

Der Sachverhalt ist frei erfunden!

Der Kanton X wird von der COVID-19-Krise schwer getroffen. Es erkranken innert kürzester Zeit sehr viele Personen schwer. Bald schon sind die Intensivbehandlungsplätze in den kantonalen Spitälern allesamt besetzt. Beatmungsgeräte stünden zwar noch weitere zur Verfügung, aber es hat keine freien Spitalzimmer mehr, in denen das medizinische Personal die Geräte einsetzen könnte. Der Regierungsrat des Kantons X will verhindern, dass schwer erkrankten Personen die Intensivbehandlung versagt werden muss. Wie im kantonalen Gesundheitsgesetz vorgesehen, will er deshalb Schulhäuser und Turnhallen der Gemeinden medizinisch umnutzen und dort weitere COVID-19-Behandlungsplätze einrichten.
Die Gemeinde Z des Kantons X ist empört über die kantonalen Pläne. Auf keinen Fall will die Gemeinde Z die gemeindeeigene Turnhalle dem Kanton zur Verfügung stellen. Gemeindevertreter von Z sind der Meinung, dies sei ein unverhältnismässiger Eingriff in die Gemeindeautonomie und daher unzulässig.

Frage 1: [4 Punkte]
Inwiefern äussert sich die BV zu den Gemeinden als Körperschaften des kantonalen Rechts?

Die Bundesverfassung widmet den Gemeinden einen eigenen Abschnitt, der aus einem einzigen Artikel besteht (Art. 50 BV) (**1 Punkt**). Danach ist die Gemeindeautonomie nach Massgabe des kantonalen Rechts gewährleistet; der Bund wird dazu angehalten, bei seinem Handeln die möglichen Auswirkungen auf die Gemeinden zu beachten und dabei insb. auf die Situation der Städte und Agglomerationen sowie der Berggebiete Rücksicht zu nehmen (**1 Punkt**). Damit setzt die BV die Existenz von Gemeinden voraus, ohne sie allerdings vorzuschreiben (**1 Punkt**). Es liegt an den Kantonen zu bestimmen, inwieweit das Kantonsgebiet in Gemeinden aufgeteilt wird und wie weit den Gemeinden Autonomie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusteht (**1 Punkt**). Dies bedeutet, dass die Kantone im Rahmen der Organisationsautonomie nach Art. 47 Abs. 2 BV frei sind, ihre eigene Gemeindestruktur einzuführen (**1 Zusatzpunkt**).

Frage 2: [6 Punkte]
Hat die Gemeinde Z ein verfassungsmässiges Recht, mit dem sie die vorübergehende Inanspruchnahme der Turnhalle durch den Kanton verhindern kann?

Soweit die Kantone Gemeinden haben, übernimmt der Bund eine Garantie ihres Bestandes (ihrer Existenz) und ihrer Autonomie (**1 Punkt**). Die Bundesgarantie ist aber eine rein formale Garantie. Das heisst, der Bund gewährleistet die

Gemeindeautonomie nach Massgabe des kantonalen Rechts (Art. 50 Abs. 1 BV) (**1 Punkt**). Mit der Autonomiebeschwerde (Art. 189 Abs. 1 lit. e BV) (**1 Punkt**) können sich die Gemeinden ans Bundesgericht wenden und sich gegen eine Verletzung ihrer Autonomie nach geltendem Recht durch den Kanton wehren (**1 Punkt**). Im vorliegenden Fall ist die vorübergehende Inanspruchnahme von gemeindeeigenen Turnhallen gemäss Sachverhalt im kantonalen Gesundheitsgesetz vorgesehen (**1 Punkt**). Deshalb kann sich die Gemeinde Z nicht mittels Autonomiebeschwerde dagegen zur Wehr setzen (**1 Punkt**).

Fortsetzung des Sachverhalts

Bald schon sind aber auch die Schulhäuser und Turnhallen allesamt belegt. Auch die übrigen Kantone wurden um dringende Unterstützung angefragt; leider haben aber auch sie nicht genügend freie Spitalkapazitäten, um zu helfen. Deshalb will der Regierungsrat nun auch auf private Villen zurückgreifen und dort weitere COVID-19-Behandlungsplätze einrichten.

Dazu will sich der Regierungsrat des Kantons X auf folgende bestehende Rechtsgrundlage stützen:

Gesundheitsverordnung des Kantons X

§ 13 Vorübergehende Inanspruchnahme von Privateigentum

1. Wenn voraussichtlich keine freien Spitalkapazitäten mehr verfügbar sind, kann der Regierungsrat vorübergehend privates Grundeigentum zur Behandlung von erkrankten Personen in Anspruch nehmen.

2. Der Regierungsrat kann für diese Inanspruchnahme eine Entschädigung sprechen.

Frage 3 [13 Punkte]:

Prüfen Sie, ob diese Rechtsgrundlage den Anforderungen des Legalitätsprinzips gerecht wird. (*Hinweis: Sollten Sie zum Schluss kommen, dass keine genügende rechtliche Grundlage vorliegt, ist eine mögliche Abstützung auf die polizeiliche Generalklausel* nicht *zu prüfen.*

Das Erfordernis des Rechtssatzes (**1 Punkt, Begriff**) verlangt eine generell-abstrakte Rechtsgrundlage. Eine Norm ist generell-abstrakt, wenn sie sich an eine unbestimmte Vielzahl von Personen wendet und eine unbestimmte Vielzahl von Fällen regelt (**1 Punkt, Erläuterung**). Die vorgeschlagene Norm richtet sich an alle Personen und

erfasst sämtliche gleichgelagerten Sachverhalte, ist also generell-abstrakt (**1 Punkt, Subsumtion**).

Das Erfordernis der genügenden Normstufe (**1 Punkt, Begriff**) verlangt, dass Wichtiges auf der Stufe des Gesetzes im formellen Sinn geregelt wird (**1 Punkt, Erläuterung**). Bei der Übernahme der tatsächlichen Verfügungsgewalt über vom Staat benötigte Objekte handelt es sich um einen schweren Eingriff in die Eigentumsgarantie, also ein Grundrecht. In diesem Bereich bestimmt die Vorschrift von Art. 36 Abs. 1 BV, dass *schwere* Eingriffe in Grundrechte gesetzespflichtig sind und deshalb die vorliegende Verordnung diesem Erfordernis nicht genügt (**1 Punkt, Subsumtion**). (*Alternativ:* Da die Inanspruchnahme nur vorübergehend ist, kann argumentiert werden, dass vorliegend kein schwerer Eingriff in die Grundrechte vorliegt und deshalb auch die Normstufe der Verordnung genügt).

Das Erfordernis der genügenden Normdichte (**1 Punkt, Begriff**) verlangt, dass die Rechtsgrundlage so präzis formuliert ist, dass die Rechtsunterworfenen ihr Verhalten danach richten können (**1 Punkt, Erläuterung**). Die vorliegende Regelung ist zu offen formuliert. Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme bleiben unklar und für die Entschädigung fehlen sie ganz. Das Bestimmtheitsgebot ist nicht erfüllt (**1 Punkt, Subsumtion**).

Das Erfordernis der genügenden Kundmachung (**1 Punkt, Begriff**) verlangt, dass eine Rechtsnorm auf dem rechtlich vorgesehenen Weg ordentlich veröffentliche wurde (**1 Punkt, Erläuterung**). Im Sachverhalt liegen keine Anhaltspunkte vor, dass der Regierungsrat von einer genügenden Veröffentlichung absehen will (**1 Punkt, Subsumtion**).

Fazit: Es mangelt es an einer hinreichenden Rechtsgrundlage, da mindestens das Erfordernis der genügenden Normdichte nicht erfüllt ist (**1 Punkt**).

Aufgabe 3 — 21 Punkte

Die gesetzlichen Grundlagen wurden für die Zwecke dieser Prüfung leicht modifiziert.

X ist Staatsangehöriger aus China und ist seit 1994 in der Schweiz als Flüchtling anerkannt. Er wohnt in Basel. Aufgrund einer schweren Krankheit kann X keiner Erwerbstätigkeit nachgehen und bezieht deshalb eine Invalidenrente (IV-Rente). Er hat zudem zwei Kinder, die aber im Ausland leben.
Y arbeitet bei der Flüchtlingshilfe Basel und berät X bei allerlei Fragestellungen. Als Jurist kennt Y die Rechtsgrundlagen betreffend IV-Rente gut. Als er von X erfährt, dass dieser im Ausland zwei Kinder habe, kommt ihm sofort Art. 35 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung in den Sinn:

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)

Art. 35 Kinderrente

1 Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind [...] Anspruch auf eine Kinderrente.

Gemäss dieser Bestimmung kommt also auch für Kinder mit Wohnsitz im Ausland eine Kinderrente in Frage. Y ist sich auf den ersten Blick nicht sicher, ob diese Bestimmung auch für Flüchtlinge wie X gilt. Alsbald besinnt sich Y aber auf folgenden Artikel aus dem völkerrechtlichen Flüchtlingsabkommen, das auch die Schweiz ratifiziert hat:

Abkommen über die Rechtstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention [FK])

Art. 24 Arbeitsgesetzgebung und soziale Sicherheit

1. Die vertragsschliessenden Staaten gewähren den rechtmässig auf ihrem Gebiet sich aufhaltenden Flüchtlingen die gleiche Behandlung wie Einheimischen mit Bezug auf:

b) [...] Invalidität [...]

Frage 1: [6 Punkte]
Sie sind juristischer Mitarbeiter bzw. juristische Mitarbeiterin bei der Flüchtlingshilfe Basel. Y fragt Sie, welche Systeme bezüglich der Geltung von Völkerrecht und Landesrecht existieren? Welchem folgt die Schweiz?

Das dualistische System (**1 Punkt**) fordert, dass Völkerrecht zuerst durch einen nationalen Rechtsakt in nationales Recht überführt werden muss (**1 Punkt**).

Das monistische System (**1 Punkt**) geht demgegenüber von der Einheit der Rechtsordnungen aus (**1 Punkt**) und lässt Völkerrecht für Behörden und Private unmittelbar bindend sein (**1 Punkt**).

Die Schweiz folgt dem monistischen System (**1 Punkt**).

Frage 2: [6 Punkte]
Kann sich X unmittelbar auf Art. 24 FK stützen?

Auch im monistischen System kann nicht jede völkerrechtliche Norm im Einzelfall unmittelbar angerufen werden. Damit sich Private wie X direkt auf völkerrechtliche Bestimmungen stützen können, müssen diese den Privaten (**1 Punkt**) individuelle Rechte und Pflichten vermitteln (**1 Punkt**) und zudem genügend bestimmt zur direkten Anwendung durch Verwaltung und Justiz sein (**1 Punkt**). Art. 24 FK vermittelt Privaten unmittelbar Rechte (Anspruch auf Leistungen bei Invalidität) und ist genügend bestimmt, sodass er ohne vorherige Präzisierung durch den Gesetzgeber im Einzelfall Grundlage eines Entscheids bilden kann (**2 Punkte für die Subsumtion**). Deshalb ist Art. 24 FK *self-executing* und X kann sich direkt darauf stützen (**1 Punkt**).

Bei stringenter Argumentation wird auch die gegenteilige Meinung zugelassen.

Fortsetzung des Sachverhalts
Gehen Sie davon aus, dass sich X direkt auf Art. 24 FK stützen kann. X beantragt mithilfe von Y beim IV-Amt Basel-Stadt zwei Kinderrenten. Das IV-Amt weist X auf folgende Gesetzesbestimmung hin:

Bundesgesetz über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und Staatenlosen in der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (BG Rechtstellung Flüchtlinge)

Art. 1	Flüchtlinge in der Schweiz; Anspruch auf Renten
Abs. 1	Flüchtlinge mit Wohnsitz in der Schweiz haben unter den gleichen Voraussetzungen wie Schweizer Bürger Anspruch auf Renten der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) sowie der Invalidenversicherung. Das Erfordernis des Wohnsitzes ist von jeder Person, für die eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen.

Als Y das sieht, muss er leer schlucken. Der letzte Satz von Art. 1 Abs. 1 BG Rechtstellung Flüchtlinge sieht auch seiner Meinung nach vor, dass X keine Kinderrenten erhält, weil seine Töchter nicht in der Schweiz, sondern im Ausland wohnen. Damit gelten für Flüchtlinge in dieser Beziehung aber andere Voraussetzungen als für Schweizerinnen und Schweizer (vgl. Art. 35 IVG).

Frage 3: [3 Punkte]
Welche Verfassungsbestimmungen sagen etwas zur Rangfolge von Völker- resp. Landesrecht?

Art. 5 Abs. 4 BV (**0.5 Punkte**) *mit plausiblen Ausführungen* (**0.5 Punkte**).
Art. 139 Abs. 3 und Art. 194 Abs. 2 BV (**0.5 Punkte**) *mit plausiblen Ausführungen* (**0.5 Punkte**).
Art. 190 BV (**0.5 Punkte**) *mit plausiblen Ausführungen* (**0.5 Punkte**).

Frage 4: [6 Punkte]

Sie schauen sich die Entstehungsgeschichte von Art. 1 Abs. 1 BG Rechtstellung Flüchtlinge an. Dabei stellen Sie fest, dass der Gesetzgeber den letzten Satz eigentlich nur auf Leistungen der AHV, nicht aber der IV beziehen wollte. Trotzdem hat der Gesetzgeber diese Formulierung gewählt, die auch Leistungen der IV erfasst. Ein allfälliger Widerspruch zu der FK wurde in der ausführlichen Parlamentsdebatte aber nicht angesprochen. Steht Art. 1 Abs. 1 BG Rechtstellung Flüchtlinge der Ausrichtung von Kinderrenten an X entgegen?

Es liegt ein Widerspruch zwischen einem Bundesgesetz (Art. 1 Abs. 1 BG Rechtstellung Flüchtlinge) und dem Völkerrecht (Art. 24 FK) vor (**1 Punkt**). Im Konfliktfall geht das die Schweiz bindende Völkerrecht dem widersprechenden Landesrecht grundsätzlich vor (vgl. auch Art. 26 f. Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge) (**1 Punkt**). Da es sich hier jedoch um ein dem Völkerrecht widersprechendes *Bundesgesetz* handelt, ist zu prüfen, ob die sog. *Schubert-Praxis* anwendbar ist und ausnahmsweise das Bundesgesetz vorgehe (**1 Punkt**). Die *Schubert-Praxis* bejaht den Vorrang eines Bundesgesetzes, wenn der Bundesgesetzgeber den Konflikt mit entgegenstehenden Staatsverträgen bewusst in Kauf genommen hat (**1 Punkt**). Vorliegend liegen aber keine Hinweise vor, dass sich der Gesetzgeber dem Widerspruch zum Völkerrecht bewusst war resp. diesen in Kauf genommen hat (**1 Punkt**). Deshalb hat Art. 24 FK Vorrang und X hat Anspruch auf zwei Kinderrenten (**1 Punkt**).

Aufgabe 4 — 17 Punkte

Brigitte Dürrenfass betreibt seit vielen Jahren schon einen Essensstand in der Winterthurer Altstadt. Im März 2020 erhält sie völlig unvorbereitet ein Schreiben des Tiefbauamts Winterthur, das Ihr bis auf Weiteres verbietet, ihren Stand weiter zu betreiben. Ihr Stand widerspreche den derzeit nötigen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften, wie sie in der COVID-19-Krise gelten, und sie habe den Essensverkauf per sofort einzustellen. Frau Dürrenfass ist mit diesem Entscheid des Tiefbauamts gar nicht einverstanden. Sie beschwert sich deshalb dagegen vor dem Winterthurer Stadtrat (Exekutivgremium der Stadt Winterthur).

Frage 1: [3 Punkte]
Gibt es eine Verfahrensgarantie der Bundesverfassung, gegen die das Vorgehen des Tiefbauamts Winterthur verstiess?

Der Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 BV gilt in allen staatlichen Verfahren, so auch im vorliegenden Verfahren, das das Tiefbauamt der Stadt Winterthur eingeleitet hat (**1 Punkt**). Einer der Teilgehalte dieses Anspruchs ist gemäss bundesgerichtlicher Praxis das Recht, sich vorgängig äussern zu können (**1 Punkt**). Indem das Tiefbauamt Frau Dürrenfass vorliegend keine vorgängige Stellungnahme ermöglicht hat (**0.5 Punkte, Subsumtion**), hat das Tiefbauamt den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt (**0.5 Punkte, Fazit**).

Der Stadtrat Winterthur lädt Frau Dürrenfass ein, schriftlich zu ihrer Beschwerde Stellung zu nehmen. Frau Dürrenfass würde ihren Standpunkt lieber mündlich erörtern, was der Stadtrat aber ablehnt und zu erkennen gibt, nur eine schriftliche Stellungnahme entgegenzunehmen.

Frage 2: [5 Punkte]
Hat Frau Dürrenfass einen grundrechtlichen Anspruch, eine mündliche Stellungnahme abgeben zu können? Muss das Verfahren zudem öffentlich sein?

Frau Dürrenfass befindet sich *nicht* in einem gerichtlichen Verfahren, weshalb sie sich nicht auf die Garantien im gerichtlichen Verfahren stützen kann (**1 Punkt**). In einem gerichtlichen Verfahren bestünde ein Anspruch auf Öffentlichkeit (Art. 30 Abs. 3 BV) (**1 Zusatzpunkt**). Für das vorliegende Verfahren gibt es aber keine Rechtsgrundlage, die einen Anspruch auf Öffentlichkeit vorsähe (**0.5 Punkte**). Auch in diesem Verfahren gilt allerdings der Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 BV (**0.5 Punkte**). Dieser Anspruch vermittelt zwar das Recht, sich vor dem Entscheid äussern zu können (**1 Punkt**). Allerdings braucht es keine mündliche Anhörung zu sein (**1**

Punkt). Frau Dürrenfass hat deshalb keinen Anspruch auf ein mündliches und öffentliches Verfahren (**1 Punkt**).

Frage 3: [2 Punkte]
Frau Dürrenfass fühlt sich im schriftlichen Ausdruck nicht sehr sicher. Sie möchte deshalb einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin beiziehen. Hat sie einen Anspruch darauf, sich in diesem Verfahren von einem Rechtsanwalt bzw. einer Rechtsanwältin helfen bzw. vertreten zu lassen?

Ein weiterer Teilgehalt des rechtlichen Gehörs nach Art. 29 Abs. 2 BV (**0.5 Punkte**) ist das Recht auf Vertretung und Verbeiständung in Gerichts- und Verwaltungsverfahren (**0.5 Punkte**). Deshalb darf sich Frau Dürrenfass von einem Rechtsanwalt bzw. einer Rechtsanwältin vertreten lassen (**1 Punkt**).

Rechtsanwalt Friedrich Gotthelf hilft Frau Dürrenfass beim Schreiben der Beschwerde. Zudem stellt er beim Stadtrat den Antrag, er solle die Stammkunden Karl Frisch und Luzius Bärlauch als Zeugen anhören, die beide bestätigen könnten, dass Frau Dürrenfass' Stand alle Hygiene- und Sicherheitsvorschriften stets eingehalten habe.
Nach der Eingabe dieser Schrift hört Frau Dürrenfass lange Zeit nichts mehr vom Stadtrat. Plötzlich erhält sie per eingeschriebener Post das Urteil des Stadtrats, in dem ihre Beschwerde abgewiesen wird; eine Zeugenbefragung wird darin nicht erwähnt. Auf telefonische Nachfrage versichert ihr der juristische Mitarbeiter des Stadtrats, dass der Stadtrat die Zeugen befragt habe.

Frage 4: [5 Punkte]
Wie ist das Vorgehen des Stadtrats zu qualifizieren?

Einleitung (0.5 Punkte)
Zu prüfen ist, ob das Vorgehen des Stadtrats gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör verstösst (Art. 29 Abs. 2 BV) oder ob allenfalls eine unzulässige Rechtsverzögerung vorliegt.

Hauptteil (grundsätzlich sind hier insgesamt bis zu 4 Punkte möglich)
Erste Möglichkeit: Ein Teilgehalt des rechtlichen Gehörs ist der Anspruch auf Mitwirkung am Beweisverfahren (**1 Punkt**). Verfahrensbeteiligte sind anlässlich einer Zeugenbefragung beizuziehen (**0.5 Punkte**). Dies ist vorliegend nicht geschehen (**0.5 Punkte**).
Zweite Möglichkeit: Ein weiterer Teilgehalt ist der Anspruch auf Begründung und Eröffnung von Entscheiden/Urteilen. Der Stadtrat hat den zugrunde gelegten Sachverhalt und die rechtliche Würdigung darzulegen (**1 Punkt**). Die Zeugenbefragung dient der Erstellung des Sachverhalts, weshalb sie im Urteil zu erwähnen ist (**0.5 Punkte**), was hier ebenfalls nicht geschehen ist (**0.5 Punkte**).

Dritte Möglichkeit: Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör ergibt sich auch der Anspruch auf Akteneinsicht (**0.5 Punkte**). Das Recht auf Akteneinsicht ermöglicht den Zugang zu den Prozessakten – so auch zu einem Protokoll der Zeugenbefragungen (**0.5 Punkte**). Die Partei muss aber zuerst über neue Akten informiert werden, um Einsicht in diese verlangen zu können (**0.5 Punkte**). Vorliegend wurde Frau Dürrenfass aber nicht über die Zeugenbefragung informiert (**0.5 Punkte**).
Vierte Möglichkeit: Art. 29 Abs. 1 BV vermittelt einen (Minimal-)Anspruch auf ein *faires Verfahren* (**0.5 Punkte**). Darin enthalten ist das Verbot der Rechtsverweigerung- oder –verzögerung (**0.5 Punkte**). Dieses wird verletzt, wenn eine Gerichts- oder Verwaltungsbehörde untätig bleibt oder das gebotene Handeln über Gebühr hinauszögert, obschon sie zum Tätigwerden verpflichtet wäre (**0.5 Punkte**). Vorliegend hat der Stadtrat gemäss Sachverhalt während langer Zeit kein Urteil gefällt (**0.5 Punkte**).

Fazit (0.5 Punkte)
Demnach verletzt das Vorgehen des Stadtrats den Anspruch auf rechtliches Gehör von Frau Dürrenfass und es kann zudem argumentiert werden kann, dass eine unzulässige Rechtsverzögerung vorliegt.

Frage 5: [2 Punkte]
Frau Dürrenfass ist mit dem Entscheid des Stadtrats nicht zufrieden. Hat sie einen verfassungsmässigen Anspruch auf eine Beurteilung durch ein Gericht?

Ja, gemäss Art. 29*a* BV (**1 Punkt**) hat jede Person bei Rechtsstreitigkeiten den Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde (**1 Punkt**).

Universität St.Gallen

Prüfungsbooklet Assessment

Rechtswissenschaft I B

Teil Schmid

Hinweise:

- **Die alten Prüfungen dienen als Lernhilfe.**
- **Die Musterlösungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.**
- **Die zitierten Stellen des Lehrbuchs oder die angegebenen Folien beziehen sich auf die zum Prüfungszeitpunkt aktuelle Auflage bzw. aktuelle Vorlesungsstruktur.**

Universität St.Gallen

Prüfung Assessmentjahr – Frühjahrssemester 2020

Name: _____ **Vorname:** _____

Muttersprache(n): Matrikel-Nr.:

Prüfungsfach: **Rechtswissenschaft I B (schriftliche Prüfung)**
2,170

Prüfungsteil: **Prof. Dr. Stefan G. Schmid (90 Minuten)**

Verantwortlich: **Prof. Dr. Stefan G. Schmid**

Bemerkungen:

Dieser Prüfungsteil umfasst 4 Aufgaben auf 19 Seiten (inkl. diesem Deckblatt). Die Punkte verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen Aufgaben:

Aufgabe 1	30 Punkte
Aufgabe 2	20 Punkte
Aufgabe 3	10 Punkte
Aufgabe 4	30 Punkte
Total	**90 Punkte**

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie bei der Bearbeitung dieser Prüfung folgende Hinweise:

1. Verwenden Sie für die Lösungen den freigehaltenen Platz unterhalb der Fragen. Sollte der zur Verfügung stehende Platz nicht genügen, bitten Sie die Prüfungsaufsicht um ein Zusatzblatt. Verwenden Sie für jede Aufgabe ein neues Zusatzblatt und kennzeichnen Sie genau, um welche Aufgabe in welchem Teil der Prüfung es sich handelt. Schreiben Sie auf jedes Zusatzblatt Ihren Namen sowie Ihre Matrikelnummer und nummerieren Sie die Blätter.
2. **Begründen Sie alle Antworten und nennen Sie, wo vorhanden, die entsprechenden rechtlichen Bestimmungen.**
3. Bitte formulieren Sie ganze Sätze und versuchen Sie, Ihre Ausführungen strukturiert und übersichtlich aufzubauen. Achten Sie auf eine leserliche Handschrift.

Bemerkung: Die Musterlösung ist ausführlich; sie enthält teilweise Alternativantworten.

Aufgabe 1: Justiz-Initiative (30 Punkte)

Am 17. September 2019 wurde festgestellt, dass die Volksinitiative «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)» mit 130 100 gültigen Unterschriften zustande gekommen sei. Sie verlangt, dass die Richterinnen und Richter des Bundesgerichts künftig durch das Los bestimmt werden. Wer zum Losverfahren zugelassen wird, soll eine unabhängige Fachkommission entscheiden. Die Richterinnen und Richter wären grundsätzlich bis fünf Jahre nach dem Erreichen des ordentlichen Rentenalters gewählt und könnten einzig in einem Abberufungsverfahren ihres Amtes enthoben werden.
Ein konkretes Abstimmungsdatum wurde noch nicht festgelegt.



Der Wortlaut der Initiative (ohne Übergangsbestimmung) lautet folgendermassen:

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Art. 145 Amtsdauer

[1] Die Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates sowie die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler werden auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Die Amtsdauer der Richterinnen und Richter des Bundesgerichts endet fünf Jahre nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters.

[2] Die Vereinigte Bundesversammlung kann auf Antrag des Bundesrates mit einer Mehrheit der Stimmenden eine Richterin oder einen Richter des Bundesgerichts abberufen, wenn diese oder dieser:

a. Amtspflichten schwer verletzt hat; oder

b. die Fähigkeit, das Amt auszuüben, auf Dauer verloren hat.

Art. 168 Abs. 1

[1] Die Bundesversammlung wählt die Mitglieder des Bundesrates, die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler sowie den General.

Art. 188a Bestimmung der Richterinnen und Richter des Bundesgerichts

[1] Die Richterinnen und Richter des Bundesgerichts werden im Losverfahren bestimmt. Das Losverfahren ist so auszugestalten, dass die Amtssprachen im Bundesgericht angemessen vertreten sind.

[2] Die Zulassung zum Losverfahren richtet sich ausschliesslich nach objektiven Kriterien der fachlichen und persönlichen Eignung für das Amt als Richterin oder Richter des Bundesgerichts.

[3] Über die Zulassung zum Losverfahren entscheidet eine Fachkommission. Die Mitglieder der Fachkommission werden vom Bundesrat für eine einmalige Amtsdauer von zwölf Jahren gewählt. Sie sind in ihrer Tätigkeit von Behörden und politischen Organisationen unabhängig.

Frage 1)

Welche Behörde stellte das Zustandekommen der Volksinitiative fest? (2 Punkte)

Die Prüfung des Zustandekommens der Volksinitiative ist Sache der Bundeskanzlei (Art. 72 BPR).

GIOVANNI BIAGGINI/THOMAS GÄCHTER/REGINA KIENER (Hrsg.), Staatsrecht, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2015, § 23 N. 91
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 24 N. 66

Frage 2)

Prüfen Sie, ob die «Justiz-Initiative» die Gültigkeitsvoraussetzung der Einheit der Materie erfüllt. (5 Punkte)
Hinweis: Führen Sie die Prüfung der Wahrung der Einheit der Materie vollständig durch, auch wenn Sie glauben, den Entscheid schon früher treffen zu können.

Einheit der Materie *(Art. 139 Abs. 3 BV, Art. 194 Abs. 2 BV; Art. 75 Abs. 1 BPR)*
Die einzelnen Teile der Initiative müssen einen sachlichen Zusammenhang aufweisen, damit die Stimmberechtigten nicht gezwungen werden, eine Initiative abzulehnen oder anzunehmen, obwohl sie vielleicht nur einen Teil der Initiative unterstützen. Der sachliche Zusammenhang (Art. 75 Abs. 2 BPR) gilt als gegeben, wenn die Regelungselemente einer Vorlage:

- *eine einheitliche Thematik betreffen; oder*
- *dasselbe Ziel verfolgen; oder*
- *in einem Zweck-Mittel-Verhältnis zueinander stehen.*

In casu:

- *Verfolgung einer einheitlichen Thematik: Die Regelungselemente der Initiative betreffen eine einheitliche Thematik, nämlich das Wahlverfahren beziehungsweise die Amtsdauer der Richterschaft des Bundesgerichts.*
- *Verfolgung desselben Ziels: Die Regelungselemente der Initiative verfolgen dasselbe Ziel, nämlich die Erhöhung der Unabhängigkeit der Richterschaft des Bundesgerichts.*
- *Zweck-Mittel-Verhältnis: Die Regelungselemente der Vorlage stehen in einem Zweck-Mittel-Verhältnis zueinander. Die Initiative setzt den Zweck (Erhöhung der Unabhängigkeit der Richterschaft des Bundesgerichts) in Bezug zu bestimmten Mitteln (u.a. Losverfahren zur Bestimmung der Richterschaft des Bundesgerichts).*

Fazit: *Die Einheit der Materie ist folglich gewahrt.*

Vorlesung 2/I Folie 29 f.
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 71 f.

Frage 3)
Volksinitiativen auf Teilrevision der Bundesverfassung können die Form der allgemeinen Anregung oder des ausgearbeiteten Entwurfs haben. Bei der «Justiz-Initiative» handelt es sich offensichtlich um einen ausgearbeiteten Entwurf. Von welcher der beiden Formen wird in der Praxis häufiger Gebrauch gemacht, und welches könnten die Gründe hierfür sein? (4 Punkte)

Der ausgearbeitete Entwurf ist verbreiteter und beliebter als die allgemeine Anregung. Der Grund hierfür ist, dass mit dem Instrument der Volksinitiative auf Teilrevision in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs Verfassungsnormen ohne Zutun und gegen den Willen des Parlaments von den Initiantinnen und Initianten angeregt und von Volk und Ständen beschlossen werden können. Der ausgearbeitete Entwurf überlässt dem Parlament somit keinen Konkretisierungsspielraum, sondern schlägt vielmehr einen definitiven Wortlaut vor. Der ausgearbeitete Entwurf ist deshalb die radikalere und zielsicherere Form. Da sie gleich viele Unterschriften erfordert wie die allgemeine Anregung, ist es nicht erstaunlich, dass praktisch nur noch Volksinitiativen in dieser Form lanciert werden.

Vorlesung 2/I FOLIE 28
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 98, 100
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 24 N. 63

Frage 4)
Ziel der «Justiz-Initiative» ist es, die Unabhängigkeit der Richterschaft des Bundesgerichts zu erhöhen. Inwiefern äussert sich bereits die zurzeit geltende Bundesverfassung zur richterlichen Unabhängigkeit? (5 Punkte)

Gemäss Art. 191c BV sind die richterlichen Behörden in ihrer rechtsprechenden Tätigkeit unabhängig und nur dem Recht verpflichtet. Grundrechtlich garantiert ist die richterliche Unabhängigkeit zudem in Art. 30 Abs. 1 BV, wonach jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, Anspruch auf ein unabhängiges Gericht hat. Die Unvereinbarkeitsregeln sind zudem nicht nur Ausdruck der personellen Gewaltenteilung, sondern stehen zugleich auch im Dienste der richterlichen Unabhängigkeit. Die Mitglieder der eidgenössischen Gerichte dürfen nicht gleichzeitig dem Nationalrat, dem Ständerat oder dem Bundesrat angehören (Art. 144 Abs. 1 BV). Zudem sieht die Bundesverfassung bei der Richterschaft des Bundesgerichts nicht eine vierjährige, sondern eine (längere) sechsjährige Amtsdauer vor (Art. 145 BV).

Vorlesung 2/V Folie 28
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 21 N. 12, 31

Frage 5)
Die «Justiz-Initiative» sieht vor, dass Richterinnen und Richter des Bundesgerichts per Losverfahren bestimmt werden, wobei über die Zulassung zum Losverfahren eine unabhängige Fachkommission entscheiden soll. Weshalb dürfte eine solche Neuregelung des Wahlverfahrens im Vergleich zur heutigen Rechtslage für parteilose Juristinnen und Juristen beziehungsweise für parteilose Richterkandidatinnen und -kandidaten vorteilhafter sein? (5 Punkte)

Die Wahl der Richterinnen und Richter des Bundesgerichts obliegt der Bundesversammlung, die für Wahlgeschäfte als Vereinigte Bundesversammlung verhandelt (Art. 168 i.V.m. Art. 157 Abs. 1 Bst. a BV; Art. 5 BGG). Damit verfügen die Richterinnen und Richter über eine hohe demokratische Legitimation. Preis dieses Wahlsystems ist eine gewisse Politisierung der Richterwahlen; sie zeigt sich insbesondere in der starken Stellung der in den Räten vertretenen politischen Parteien bei der Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten. In der Wahlpraxis verfolgt die Vereinigte Bundesversammlung nämlich einen freiwilligen Parteienproporz. Die Wählbarkeit an das Bundesgericht ist faktisch an die Mitgliedschaft in einer politischen Partei geknüpft. Zumeist haben parteilose Kandidatinnen und Kandidaten trotz bester Qualifikation kaum Wahlchancen. Durch das Losverfahren und die Vorauswahl durch eine unabhängige Fachkommission hätten somit auch parteilose Kandidatinnen und Kandidaten die faktische Möglichkeit, Bundesrichterin bzw. Bundesrichter zu werden.

Vorlesung 2/V Folie 29
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 21 N. 30

Frage 6)
Gemäss der «Justiz-Initiative» soll die Amtsdauer der Richterinnen und Richter des Bundesgerichts grundsätzlich fünf Jahre nach dem Erreichen des ordentlichen Rentenalters enden. Wie ist die Amtsdauer der Bundesrichterinnen und Bundesrichter nach zurzeit geltendem Recht geregelt? (5 Punkte)

Die Wahl der Richterschaft des Bundesgerichts erfolgt auf eine feste Amtsdauer von sechs Jahren (Art. 145 Satz 2 BV; Art. 9 Abs. 1 BGG). Nach Ablauf der Amtsdauer müssen sich alle Richterinnen und Richter der Wiederwahl stellen. Die Bundesverfassung kennt keine Amtszeitbeschränkung für Bundesrichterinnen und Bundesrichter. Im klaren Widerspruch zu Art. 143 BV, der keine obere Alterslimite vorsieht, hat der Gesetzgeber jedoch die Regel aufgestellt, dass die Richterinnen und Richter des Bundesgerichts am Ende jenes Jahres aus ihrem Amt ausscheiden, in dem sie das 68. Altersjahr vollenden (Art. 9 Abs. 2 BGG). Eine Abberufung von Mitgliedern des Bundesgerichts vor Ablauf der Amtsdauer ist weder in der Bundesverfassung noch gesetzlich vorgesehen.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 21 N. 36 ff.

Frage 7)
Inwiefern könnte die Regelung der «Justiz-Initiative» betreffend Amtsdauer die richterliche Unabhängigkeit tatsächlich erhöhen? Sehen Sie in einer solchen Regelung auch Gefahren? (4 Punkte)

- ***Erhöhte richterliche Unabhängigkeit***

In der heute vorgesehenen Koppelung einer relativ kurzen Amtsdauer von sechs Jahren mit dem Erfordernis der Wiederwahl liegt eine erhebliche Relativierung der inneren Entscheidfreiheit der Richterin bzw. des Richters: Weil die Nichtwiederwahl nicht begründet werden muss, kann sie aus irgendwelchen Gründen und damit auch wegen einer nicht genehmen Rechtsprechung erfolgen. Wer aber befürchten muss, nach Ablauf der Amtsdauer wegen missliebiger Urteile nicht wiedergewählt zu werden, kann nicht in voller innerer Unabhängigkeit entscheiden; es besteht jedenfalls dem äusseren Anschein nach die Gefahr, dass die Rechtsprechung gerade in politisch heiklen und gesellschaftspolitisch umstrittenen Fällen an den mutmasslichen Erwartungen der Wiederwahlbehörde ausgerichtet werden könnte. Dieser Problematik könnte durch die «Justiz-Initiative» (mit der Regelung, wonach Richterinnen und Richter grundsätzlich bis fünf Jahre nach dem Erreichen des ordentlichen Rentenalters gewählt sind) tatsächlich begegnet werden.

- ***Gefahren***

Allerdings ist eine Neuregelung, wie sie der Initiativtext vorsieht, auch mit Gefahren verbunden, da das heute geltende System durchaus Vorteile hat: Mit der zeitlich beschränkten Amtsdauer und dem Erfordernis der Wiederwahl wird das demokratische Prinzip betont, indem die Dritte Gewalt in der periodischen Wiederwahl der Amtsträger stets neu demokratisch legitimiert werden muss; die Beschränkung der Amtsdauer steht zudem auch im Dienst der Justizaufsicht. Die demokratische Legitimation sowie die Justizaufsicht würden eher geschwächt.

Die «Justiz-Initiative» versucht zwar die Justizaufsicht zu gewährleisten, indem die Bundesversammlung auf Antrag des Bundesrates eine Richterin oder einen Richter des Bundesgerichts abberufen kann. Jedoch kann sich ein solches Abberufungsrecht ähnlich wie das Erfordernis der Wiederwahl negativ auf die richterliche Unabhängigkeit auswirken.

Anmerkung: Weitere gehaltvolle Ausführungen wurden ebenfalls bepunktet.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 21 N. 39 f.

Aufgabe 2: Rechtsetzungsseminar (20 Punkte)

Die liberal-konservative Fortschrittspartei möchte zukünftig auf Bundesebene vermehrt Einfluss auf die Rechtsetzung nehmen. Die Parteileitung hat deshalb entschieden, sämtliche Parteimitglieder zu einem sogenannten Rechtsetzungsseminar einzuladen. An diesem Seminar wird so allerlei gesagt und behauptet. Nehmen Sie zu jeder Aussage Stellung, und legen Sie dar, inwiefern sie zutrifft oder nicht zutrifft.

Aussage 1)
Der Anstoss zu einer Verfassungsrevision kann einzig vom Stimmvolk ausgehen. (2 Punkte)

Trifft nicht zu. Der Anstoss zu einer Verfassungsrevision kann auch von der Bundesversammlung (Art. 160 Abs. 1 BV), von den Kantonen (Art. 160 Abs. 1 BV) oder vom Bundesrat (Art. 181 BV) ausgehen.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 67, 86

Aussage 2)
Bei einem direkten Gegenentwurf wird der Volksinitiative eine Gesetzesänderung oder ein neues Gesetz gegenübergestellt. (2 Punkte)

Trifft nicht zu. Bei einem direkten Gegenentwurf erarbeitet die Bundesversammlung eine Verfassungsänderung (Art. 101 ParlG), die häufig einen Kompromiss zwischen der geltenden Rechtslage und dem Begehren des Initiativkomitees darstellt. Bei einem indirekten Gegenvorschlag wird der Volksinitiative eine Erlassänderung oder ein neuer Erlass unterhalb der Verfassungsstufe (Gesetz, Verordnung) gegenübergestellt.

Vorlesung 2. Teil (I) Folie 26
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 101 ff.

Aussage 3)
Auf Bundesebene verfügen die Stimmberechtigten über kein Initiativrecht für Gesetze. (2 Punkte)

Trifft zu. Das Volk verfügt, anders als in sämtlichen Kantonen, auf Bundesebene weder über die Gesetzesinitiative noch über das Initiativrecht im Sinn von Art. 160 BV. Es kann grundsätzlich nur auf dem Weg der Volksinitiative, die auf Revision der Bundesverfassung gerichtet ist, Beratungsgegenstände in die Bundesversammlung einbringen.

Vorlesung 2/I Folie 23
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 16
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 24 N. 58

Aussage 4)
National- und Ständerat müssen für die Verabschiedung eines Bundesgesetzes übereinstimmende Beschlüsse fassen. (2 Punkte)

Trifft zu. Beide Räte sind gleichberechtigt (Art. 148 Abs. 2 BV) und müssen deshalb für die Verabschiedung eines Bundesgesetzes identische Beschlüsse fassen (Art. 156 Abs. 2 BV). Unterscheidet sich das Ergebnis der Beratungen in beiden Räten, wird versucht, im Differenzbereinigungsverfahren (Art. 89 ff. ParlG) Übereinstimmung zu erzielen. Nur wenn dies gelingt, kommt ein Beschluss der Bundesversammlung zustande, andernfalls ist das Gesetzgebungsvorhaben gescheitert.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 33 ff.

Aussage 5)
Das Handlungsinstrument der Motion ermöglicht es der Bundesversammlung, ihre Gesetzgebungsfunktion unabhängig von Bundesrat und Verwaltung wahrzunehmen. (2 Punkte)

Trifft nicht zu. Die Motion ist ein Auftrag an den Bundesrat, der Bundesversammlung einen Entwurf zu einem Erlass vorzulegen oder eine Massnahme zu treffen (Art. 171 BV; Art. 120 ff. ParlG). Die obige Aussage trifft auf die parlamentarische Initiative zu, da bei dieser anders als gerade bei der Motion die Bundesversammlung das Geschäft in den eigenen Händen behält und demnach nicht auf Kooperation von Bundesrat und Verwaltung angewiesen ist (Art. 160 Abs. 1 BV; Art. 107 ff. ParlG).

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 10 ff.

Aussage 6)
Die Aushandlung und die Unterzeichnung von völkerrechtlichen Verträgen fallen grundsätzlich in die Zuständigkeit der Bundesversammlung. (2 Punkte)

Trifft nicht zu. Die Aushandlung und Unterzeichnung von Staatsverträgen fallen grundsätzlich in den Kompetenzbereich des Bundesrates (Art. 184 Abs. 2 BV), wobei er (immerhin) die Mitwirkungsrechte der Bundesversammlung zu wahren hat (Art. 184 Abs. 1 BV, Art. 166 Abs. 1 BV). Der Abschluss völkerrechtlicher Verträge bedarf u.U. der Genehmigung durch die Bundesversammlung (Art. 166 Abs. 2 BV).

Vorlesung 2/V Folie 23
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 140 ff.

Aussage 7)
Vollziehungsverordnungen bedürfen einer Gesetzesdelegation. (2 Punkte)

Trifft nicht zu. Da eine Vollziehungsverordnung die Regelung eines Bundesgesetzes lediglich konkretisiert und spezifiziert und insbes. den Bürgerinnen und Bürgern keine neuen Pflichten auferlegt, bedarf sie keiner Gesetzesdelegation. Die Kompetenz des Bundesrates zum Erlass von Vollziehungsverordnungen ist in der allgemeinen Vollzugskompetenz von Art. 182 Abs. 2 BV enthalten.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 22 N. 25 ff.

Aussage 8)
Die Bundesversammlung kann Notverordnungen erlassen. (2 Punkte)

Trifft zu. Die Bundesversammlung trifft Massnahmen zur Wahrung der äusseren Sicherheit, Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz sowie zur Wahrung der inneren Sicherheit und kann in diesem Zusammenhang – aber nur, wenn ausserordentliche Umstände es erfordern – direkt gestützt auf die Verfassung Verordnungen erlassen (Art. 173 Abs. 1 Bst. c BV).

Gastvortrag Folie 10
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 53

Aussage 9)
Gegen wichtige Bundesverordnungen wie die Covid-19-Verordnung 2 kann das Referendum ergriffen werden. (2 Punkte)

Trifft nicht zu. Gemäss Art. 141 Abs. 1 BV unterstehen nur Bundesgesetze sowie bestimmte völkerrechtliche Verträge und Bundesbeschlüsse dem fakultativen Referendum. Selbst wichtige Verordnungen unterstehen daher nicht dem Referendum, weshalb nach der Verabschiedung einer Verordnung keine Referendumsfrist angesetzt bzw. keine Referendumsabstimmung durchgeführt werden muss.

Vorlesung 2/1 Folie 42
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 126
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 24 N. 19

Aussage 10)

Tagungsort der Bundesversammlung ist zwingend das Bundeshaus in Bern.
(2 Punkte)

Trifft nicht zu. Die Bundesversammlung tagt zwar grundsätzlich in Bern (Art. 32 Abs. 1 ParlG). Sie kann jedoch mit einfachem Bundesbeschluss beschliessen, ausnahmsweise an einem anderen Ort zu tagen (Art. 32 Abs. 2 ParlG). So tagte die Bundesversammlung aufgrund von Renovationsarbeiten des Bundeshauses 1993 in Genf, 2001 in Lugano und 2006 in Flims. Die ausserordentliche Session vom 4.– 6. Mai 2020 fand aufgrund der Corona-Pandemie nicht im Bundeshaus, sondern in der Bernexpo statt.

Gastvortrag Folie 20
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 77

Aufgabe 3: Arme Frieda! (10 Punkte)

Ausgangssachverhalt:
Frieda und Luca, beide 30 Jahre alt und ledig, arbeiten seit einem Jahr beim Migrationsamt des Kantons Y. Beide verfügen über die gleiche Qualifikation (Masterabschluss in Rechtswissenschaften HSG) und besitzen gleich viel Arbeitserfahrung. Frieda und Luca haben absolut gleichwertige Arbeit zu verrichten und arbeiten beide in einem 100% Pensum. Während Luca monatlich 8000 Franken verdient, muss sich Frieda mit monatlich 5000 Franken begnügen.

Frage 1)
Frieda sieht in der Lohndiskrepanz eine unmittelbare Verletzung ihrer Grundrechte. Hat sie recht? (4 Punkte)

Vorliegend könnte die Rechtsgleichheit verletzt sein, zumal Frieda als natürliche Person Grundrechtsträgerin und das Migrationsamt Grundrechtsadressatin ist. Gemäss dem Lohngleichheitsgebot von Art. 8 Abs. 3 Satz 3 BV haben Mann und Frau Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Lohnunterschiede sind zulässig, sofern sie auf objektiven Kriterien wie z.B. Alter, Erfahrung oder Qualifikationsgrad basieren. Dem Sachverhalt zufolge basiert die Lohndiskrepanz nicht auf solchen objektiven Kriterien, weshalb der Lohngleichheitssatz vorliegend verletzt sein dürfte.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 38 N. 52 ff.

Sachverhaltserweiterung:
Nehmen Sie nun an, Frieda und Luca arbeiten nicht beim kantonalen Migrationsamt, sondern in der Rechtsabteilung der Zürcher Privatbank «Julius Leu AG». Ansonsten ist vom Ausgangssachverhalt auszugehen.

Frage 2)
Auch in dieser Konstellation erblickt Frieda eine unmittelbare Verletzung ihrer Grundrechte. Hat sie recht? (2 Punkte)

Ja. Der Lohngleichheitssatz entfaltet nicht nur gegenüber jedem staatlichen Arbeitgeber Wirkung, sondern auch gegenüber Privaten. Art. 8 Abs. 3 Satz 3 BV kommt somit direkte Drittwirkung zu.

Vorlesung 2/II Folie 14
Vorlesung 2/III Folie 38
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 38 N. 52

Sachverhaltserweiterung:

Gehen Sie nun wieder vom Ausgangssachverhalt aus, wonach Frieda beim Migrationsamt des Kantons Y. arbeitet. Da der stellvertretende Abteilungsleiter des Rechtsdienstes des Migrationsamts demnächst in Pension geht, wird die Stelle neu ausgeschrieben. Frieda bewirbt sich sogleich. Einige Tage später erhält sie jedoch vom Amtsleiter des Migrationsamts, der für die Mitarbeiterrekrutierung zuständig ist, eine Absage. Die Absage wird dadurch begründet, dass Frieda aufgrund ihrer Sympathie für Greta Thunberg und die Klimabewegung ungeeignet sei.

Frage 3)

Frieda ist über die Absage und die Begründung empört und sieht darin eine Verletzung ihrer Grundrechte. Hat sie recht? (4 Punkte)
Hinweis: Auf Freiheitsrechte ist nicht einzugehen.

Art. 8 Abs. 2 BV besagt, dass niemand diskriminiert werden darf, namentlich nicht wegen der politischen Überzeugung. Es könnte demnach eine direkte Diskriminierung vorliegen, zumal Frieda als natürliche Person Grundrechtsträgerin und das Migrationsamt als kantonale Behörde Grundrechtsadressatin ist. Das Anknüpfen an ein verpöntes Merkmal ist nicht absolut unzulässig. Es begründet den blossen Verdacht einer unzulässigen Differenzierung, der nur durch eine qualifizierte Rechtfertigung umgestossen werden kann.
Da die Absage einzig mit der politischen Einstellung von Frieda begründet und eine Rechtfertigung nicht möglich sein wird, da die Sympathie für die Klimabewegung keinen Einfluss auf die Eignung von Frieda haben dürfte, liegt eine direkte Diskriminierung vor.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 38 N. 38 ff.

Aufgabe 4: Gerichtsverhandlung (30 Punkte)

Die Staatsanwaltschaft Zürich erhob Anklage in einem Strafverfahren, in dem es hauptsächlich um häusliche Gewalt ging. Der Angeklagte und die Geschädigte lernten sich in einer therapeutischen Einrichtung kennen, wo sie sich nach traumatischen Erlebnissen befanden. Nach der Entlassung lebten sie bis zum Vorfall, welcher zur Anklage führte, zusammen. Beide litten weiterhin an erheblichen psychischen Problemen. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, die Geschädigte im Verlaufe eines Streits mehrmals gewürgt zu haben, zuletzt mit einem Kabel.
Im Januar 2020 fand vor dem Bezirksgericht Zürich die Hauptverhandlung statt. Zum Schutz der Persönlichkeit des Angeklagten und des Opfers hatte das Bezirksgericht die Öffentlichkeit schon vor der Verhandlung vom Verfahren ausgeschlossen, die akkreditierten Gerichtsberichterstatter dagegen (mit Auflagen) zugelassen.
Zu Beginn der Hauptverhandlung wies der vorsitzende Richter die Gerichtsberichterstatter darauf hin, der Ausschluss der Öffentlichkeit habe zur Folge, dass von den Verfahrensbeteiligten keine persönlichen Daten wie Name oder Wohnort und keine Bilder publiziert werden dürften, seien diese inner- oder ausserhalb des Gerichtsgebäudes aufgenommen worden. Der Vorsitzende fragte die anwesenden Gerichtsberichterstatter, ob sie Gewähr dafür bieten können, dass diese Auflage eingehalten und dementsprechend die Privatsphäre der Prozessbeteiligten in diesem Sinne gewahrt werde. Wer dies nicht garantieren könne, werde von der Verhandlung ausgeschlossen, so der Vorsitzende weiter. Während die anderen Gerichtsberichterstatter dies dem Vorsitzenden zusicherten, antwortete X., Gerichtsberichterstatter der Tageszeitung «Blick», er könne hier und jetzt «für gar nichts» garantieren, da über die Art und Weise der Berichterstattung einzig der Chefredaktor des «Blick» entscheide. Daraufhin wurde X. von der Verhandlung ausgeschlossen.

Art. 70 der Schweizerischen Strafprozessordnung (= Bundesgesetz), die von der hierfür zuständigen Bundesversammlung erlassen wurde, lautet wie folgt:

Art. 70 Einschränkungen und Ausschluss der Öffentlichkeit

[1] Das Gericht kann die Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen ganz oder teilweise ausschliessen, wenn:

a. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder schutzwürdige Interessen einer beteiligten Person, insbesondere des Opfers, dies erfordern;
b. grosser Andrang herrscht.

[2] Ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen, so können sich die beschuldigte Person, das Opfer und die Privatklägerschaft von höchstens drei Vertrauenspersonen begleiten lassen.

[3] Das Gericht kann Gerichtsberichterstatterinnen und Gerichtsberichterstattern und weiteren Personen, die ein berechtigtes Interesse haben, unter bestimmten Auflagen den Zutritt zu Verhandlungen gestatten, die nach Absatz 1 nicht öffentlich sind.

[4] Wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen, so eröffnet das Gericht das Urteil in einer öffentlichen Verhandlung oder orientiert die Öffentlichkeit.

X. gelangt nun an Sie mit der Frage, ob aufgrund der Auflage und des darauffolgenden Ausschlusses von der Gerichtsverhandlung eine Verletzung seiner Grundrechte vorliege.

- Prüfen Sie anhand der Prüfkriterien, ob ein Grundrechtsfall vorliegt und ob die Voraussetzungen für die zulässige Einschränkung eines Freiheitsrechts erfüllt sind.
- Gehen Sie bei der Prüfung der Grundrechtsrelevanz mit Ausnahme der Wirtschaftsfreiheit auf **alle Freiheitsrechte der Bundesverfassung** ein**,** die aus Sicht des X. im vorliegenden Fall berührt/tangiert sein könnten. Konzentrieren Sie sich bei der nachfolgenden Prüfung der Zulässigkeit der Einschränkung aber auf nur **ein einziges berührtes Freiheitsrecht**.
- **Prüfen Sie alle Kriterien, auch wenn Sie glauben, den Entscheid schon früher treffen zu können.**
- Prozessuale Fragen können Sie weglassen.

Hinweis: Auf die Wirtschaftsfreiheit ist **nicht** einzugehen.

Prüfkriterien 1: Prüfung der Grundrechtsrelevanz (insgesamt 10 Punkte)

a) Rechtsgrundlagen der Freiheitsrechte

Im vorliegenden Fall könnten die Meinungs- und Informationsfreiheit (Art. 16 BV) sowie die Medienfreiheit (17 BV) berührt sein.

b) Sachlicher Schutzbereich (Schutzobjekt)

Meinungsfreiheit:

Das Recht auf Meinungsfreiheit beinhaltet das Recht jeder Person, sich ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten (Art. 16 Abs. 2 BV). Geschützt sind alle Mittel, die sich zur Kommunikation eignen (Wort, Schrift, Gebärden, künstlerische Formen etc.). Der Begriff der Meinungsfreiheit ist weit zu verstehen. Eine Meinung fällt unabhängig von ihrem Inhalt in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit.

In casu: *X. wollte über die Verhandlung berichten und dabei seine Meinung betreffend das Straffverfahren kundtun. Aufgrund der Auflage und dem darauffolgenden Ausschluss von der Gerichtsverhandlung ist dies X. nur beschränkt möglich.*

Fazit: *Der sachliche Schutzbereich der Meinungsfreiheit ist berührt.*

Informationsfreiheit:

In der geltenden Bundesverfassung ist die Informationsfreiheit nicht bloss ein Bestandteil von Art. 16 Abs. 1 BV, sondern ein eigenständiger grundrechtlicher Anspruch aus Art. 16 Abs. 3 BV. Die Informationsfreiheit dient der Vorbereitung für die Ausübung der Meinungsfreiheit. Denn die freie Weitergabe von Informationen sowie die Möglichkeit, unterschiedliche Ansichten zur Kenntnis zu nehmen, sind unerlässliche Voraussetzungen für eine eigenständige Meinungsbildung. Die Informationsfreiheit schützt jede Person im Empfangen, Beschaffen und Verbreiten von Informationen. Von der Informationsfreiheit ist auch das Recht auf aktives Beschaffen von Informationen erfasst. Allerdings besteht der

grundrechtlich geschützte Informationsanspruch nur hinsichtlich allgemein zugänglicher Quellen. Als allgemein zugänglich gelten grds. auch Gerichtsverhandlungen (vgl. Art. 30 Abs. 3 BV).
In casu: *X. wollte sich Informationen beschaffen, um danach in einem Zeitungsbericht über das Strafverfahren zu berichten. Die Auflage und der darauffolgende Ausschluss von der Gerichtsverhandlung haben zur Folge, dass sich X. diese Informationen nur beschränkt beschaffen kann.*
Fazit: *Der sachliche Schutzbereich der Informationsfreiheit ist berührt.*

Medienfreiheit:
Art. 17 Abs. 1 BV schützt die einzelne Person insoweit, als sie sich der Medien und Massenkommunikation bedient, um ihre Meinung zu äussern und zu verbreiten. Sie soll dies ohne staatliche Eingriffe tun können. Geschützt sind alle Arten und Formen von Medien. Des Weiteren beinhaltet die Medienfreiheit ein Verbot der Zensur (Art. 17 Abs. 2 BV) und das Redaktionsgeheimnis muss gewährleistet werden (Art. 17 Abs. 3 BV).
In casu: *Die Auflage und der Ausschluss von der Gerichtsverhandlung erschweren es dem X., seine Meinung betreffend das Strafverfahren in der Tageszeitung Blick zu äussern und zu verbreiten.*
Fazit: *Der sachliche Schutzbereich der Medienfreiheit ist berührt.*

c) Persönlicher Schutzbereich (Grundrechtsträgerschaft)
Die Kommunikationsgrundrechte stehen allen Personen zu: natürlichen und juristischen, ausländischen und schweizerischen, minderjährigen und volljährigen.
In casu*: X. ist eine natürliche Person.*
Fazit: *X. ist Träger der Kommunikationsgrundrechte.*

d) Adressat
Adressat der Kommunikationsgrundrechte ist der Staat bzw. die staatlichen Behörden auf allen Ebenen der staatlichen Tätigkeit (Bund, Kantone, Gemeinden).
In casu: *Beim Bezirksgericht Zürich handelt es sich um eine staatliche Behörde auf Ebene Kanton.*
Fazit: *Das Bezirksgericht Zürich ist Adressat der Kommunikationsgrundrechte.*

e) Zwischenergebnis der Vorprüfung
Es liegt ein Grundrechtsfall vor.

Prüfkriterien 2: Prüfung der Zulässigkeit der Einschränkung (Art. 36 BV) (insgesamt 20 Punkte)

a) Gesetzliche Grundlage

Art. 36 Abs. 1 BV

Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Eine Ausnahme bildet die polizeiliche Generalklausel (Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr).

Gemäss Art. 70 Abs. 1 Bst. a der Strafprozessordnung (kurz StPO) kann das Gericht die Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen ganz ausschliessen, wenn schutzwürdige Interessen einer beteiligten Person, insbesondere des Opfers, dies erfordern. Gemäss Art. 70 Abs. 3 StPO kann das Gericht Gerichtsberichterstatterinnen und Gerichtsberichterstattern unter bestimmten Auflagen den Zutritt zu Verhandlungen gestatten, die nach Absatz 1 nicht öffentlich sind. Erfüllt eine Gerichtsberichterstatterin oder ein Gerichtsberichterstatter die Auflage nicht, erfüllt sie oder er die entsprechende Voraussetzung für den Zutritt nach Art. 70 Abs. 3 StPO nicht und es bleibt damit beim Ausschluss gemäss Art. 70 Abs. 1 StPO.

Erfordernis des Rechtssatzes

- *Generell-abstrakte Norm: Die Freiheitsbeschränkung muss grundsätzlich in einem Rechtssatz, d.h. in einer generell-abstrakten Norm, vorgesehen sein (Art. 22 Abs. 4 ParlG).*
- *Genügende Bestimmtheit: Ein Rechtssatz muss so präzise formuliert sein, dass die Bürgerinnen und Bürger ihr Verhalten danach richten und die Folgen eines bestimmten Verhaltens mit einem entsprechenden Grad an Gewissheit erkennen können.*

In casu: *Das Gericht stützt sich auf Art. 70 StPO, mithin eine generell-abstrakte Norm. Art. 70 StPO ist so präzise formuliert, dass jede Bürgerin und jeder Bürger ihr/sein Verhalten danach richten kann. Denn aus Art. 70 StPO ergibt sich ohne Weiteres, dass Gerichtsberichterstatterinnen und Gerichtsberichterstatter, die sich nicht an die Auflage halten, von der Verhandlung ausgeschlossen werden dürfen. Die Anforderungen an die Normdichte sind damit erfüllt.*

Erfordernis der Gesetzesform

Schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein, d.h. in einem Gesetz im formellen Sinn (Art. 36 Abs. 1 Satz 2 BV). Nicht schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen können auch in Erlassen niedrigerer Stufe vorgesehen sein, insbesondere in einer Verordnung.

In casu: *Die Strafprozessordnung wurde vom zuständigen Organ des Bundes, der Bundesversammlung, erlassen. Die Strafprozessordnung stellt eine formell-gesetzliche Grundlage dar, weshalb insoweit die Schwere des Grundrechtseingriffs unerheblich ist.*

Gesamtfazit gesetzliche Grundlage:

Sowohl das Erfordernis des bestimmten Rechtssatzes als auch jenes der Gesetzesform sind erfüllt. Art. 70 StPO stellt eine hinreichende gesetzliche Grundlage sowohl für die Auflage als auch für den Ausschluss von X. und somit auch für die Einschränkung seiner Kommunikationsgrundrechte dar.

b) Rechtfertigende Eingriffsinteressen

Art. 36 Abs. 2 BV

Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.

Im öffentlichen Interesse liegt alles, was der Staat zum Gemeinwohl vorkehren muss, um eine ihm obliegende Aufgabe zu erfüllen. Als hinreichende öffentliche Interessen gelten z.B. die Polizeigüter (Ruhe und Ordnung, öffentliche Sicherheit, öffentliche Gesundheit, öffentliche Sittlichkeit, Treu und Glauben im Geschäftsverkehr). Das Eingriffsinteresse des Schutzes von Grundrechten Dritter macht deutlich, dass die Grundrechtsansprüche verschiedener Grundrechtsträger miteinander kollidieren können.
In casu: *Der Schutz der Polizeigüter steht nicht im Vordergrund. Vielmehr kollidieren hier Grundrechtsansprüche verschiedener Grundrechtsträger, weshalb der Eingriff aufgrund des Schutzes von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein könnte. Die Auflage und der Ausschluss von X. erfolgten zum Schutz der Persönlichkeit des Opfers und des Angeklagten. Diese litten gemäss Sachverhalt auch noch nach der Entlassung aus einer therapeutischen Einrichtung, wo sie sich aufgrund traumatischer Erlebnisse befunden hatten, an erheblichen psychischen Problemen. Damit sind sie besonders schutzbedürftig. Die Offenlegung ihrer Identität hätte nicht nur ihre persönliche und berufliche Lage erschweren, sondern zudem ihren psychischen Zustand weiter verschlechtern können. Sie haben ein Recht auf Schutz der Privatsphäre (Art. 13 BV) und der persönlichen Freiheit/geistigen Unversehrtheit (Art. 10 Abs. 2 BV).*
Fazit: *Es gilt Grundrechte Dritter zu schützen.*

c) Verhältnismässigkeit

Art. 36 Abs. 3 BV

Eignung: *Die Massnahme muss geeignet sein, den angestrebten Zweck zu erreichen.*
In casu*: Die Auflage sowie der Ausschluss von X. sind geeignet, die Grundrechte der Prozessbeteiligten zu schützen.*
Fazit: *Die Eignung ist gegeben.*

Erforderlichkeit*:*
Die Massnahme muss den geringst möglichen Eingriff darstellen; es darf keine gleichermassen geeignete, mildere Massnahme geben, die zum gleichen Ziel führen würde.
In casu*: Eine mildere Massnahme, die den verfolgten Zweck ebenfalls hätte erreichen können, stand vorliegend nicht zu Verfügung. So wurde die Öffentlichkeit nicht vollständig von der Verhandlung ausgeschlossen, sondern den Gerichtsberichterstatterinnen und Gerichtsberichterstattern war es möglich, bei Einhaltung der Auflagen an der Verhandlung teilzunehmen. Der vorsitzende Richter hat die anwesenden Personen auf die Auflage aufmerksam gemacht und angedroht, bei Nichterfüllung der Auflage die jeweilige medienschaffende Person auszuschliessen. Erst als X. mit einer provokativen Wortwahl die Garantie der Einhaltung der Auflage verneinte, wurde er ausgeschlossen. So blieb dem Gericht nichts anderes übrig, als X. auszuschliessen. Der Staat selbst hat nämlich an einer Persönlichkeitsverletzung teil, wenn er diese während oder im Anschluss an eine Gerichtsverhandlung duldet. So wenig er zulassen darf, dass an der Verhandlung gegen die Prozessbeteiligten von Privaten Gewalttätigkeiten verübt werden, darf er es hinnehmen, dass ihre Persönlichkeitsrechte verletzt werden.*
Fazit: *Die Erforderlichkeit ist gegeben.*

Zumutbarkeit:
Die Massnahme darf zu keinem Missverhältnis zwischen Eingriffszweck und Eingriffswirkung führen (Zweck-Mittel-Verhältnis). Das öffentliche Interessen an der Einschränkung des Grundrechts sowie der Schutz von Grundrechten Dritter muss das private Interesse an der ungehinderten Ausübung des Grundrechts überwiegen.

In casu (inkl. Abwägung):
Öffentliches Interesse an der Einschränkung: Keine ersichtlich.
Schutz der Grundrechte von Dritten: Verweis auf oben.
*Privates Interesse**:** Interesse von X. an der Gerichtsverhandlung teilzunehmen und für die Leserschaft des Blicks darüber zu berichten.*
Dem Schutz der Persönlichkeit des Angeklagten und v.a. des Opfers im Strafverfahren kommt erhebliche Bedeutung zu. Zudem wäre X. nicht ausgeschlossen worden, hätte er wie die anderen Gerichtsberichterstatterinnen und Gerichtsberichterstatter garantiert, die Auflage nicht zu verletzen. Eine objektive Berichterstattung wäre auch unter Einhaltung der Auflage möglich gewesen.
***Fazit:** Die Zumutbarkeit ist gegeben.*

***Zwischenergebnis Verhältnismässigkeit**: Die Verhältnismässigkeit der Einschränkung ist im gegebenen Fall zu bejahen.*

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wurde, sofern überzeugend begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

d) Schutz des Kerngehalts

Art. 36 Abs. 4 BV
In den Kerngehalt eines Grundrechts darf unter keinen Umständen eingegriffen werden. Ein Freiheitsrecht darf weder völlig unterdrückt noch seines Gehalts als fundamentale Institution der Rechtsordnung entleert werden.
Der Kern der Medienfreiheit betrifft die systematische Vorzensur im Sinne einer planmässigen und systematischen Inhaltskontrolle von Medienerzeugnissen.

***In casu:** Durch die Auflage und den Ausschluss von X. sollte verhindert werden, dass X. die Grundrechte der Prozessbeteiligten verletzt. Es handelt sich hierbei um einen Präventiveingriff im Einzelfall und nicht um eine systematische Vorzensur.*
***Fazit:**Der Kerngehalt der Medienfreiheit wird gewahrt.*

Alternativargumentation falls die Meinungsfreiheit oder Informationsfreiheit gewählt wurde:

In den Kerngehalt eines Grundrechts darf unter keinen Umständen eingegriffen werden. Ein Freiheitsrecht darf weder völlig unterdrückt noch seines Gehalts als fundamentale Institution der Rechtsordnung entleert werden.
Die Einschränkung der Meinungsfreiheit/Informationsfreiheit weist im Hinblick auf den Kerngehalt eine Besonderheit auf. Das Verbot der Vorzensur im Sinne einer systematischen, vorgängigen und allgemeinen Inhaltskontrolle beabsichtigter Meinungsäusserungen gemäss Art. 17 Abs. 2 BV gehört zum unantastbaren Kerngehalt der Meinungs- und Informationsfreiheit. Zwar ist das Zensurverbot in Art. 17 Abs. 2 BV bei der Medienfreiheit verankert, da dort sein Hauptanwendungsbereich liegt. Es gilt jedoch für alle Kommunikationsgrundrechte.
Zudem erfährt das «forum internum», das heisst der Bereich der inneren Meinungsbildung, absoluten Schutz. In jedem Fall unzulässig ist es z.B., einen Menschen mit Mitteln der Gehirnwäsche oder dem Gebrauch von Psychopharmaka zur inneren Identifikation mit einer Meinung zu zwingen, die er ablehnt.
***In casu:** Durch die Auflage und den Ausschluss von X. sollte verhindert werden, dass X. die Grundrechte der Prozessbeteiligten verletzt. Es handelt sich hierbei um einen Präventiveingriff im Einzelfall*

und nicht um eine systematische vorgängige und allgemeine Inhaltskontrolle beabsichtigter Meinungsäusserungen.
Fazit: *Der Kerngehalt der Meinungsfreiheit/Informationsfreiheit wird gewahrt.*

e) Gesamtergebnis

Die Auflage sowie der darauffolgende Ausschluss von der Gerichtsverhandlung stellen keinen unzulässigen Eingriff in die Grundrechte von X. dar.

Anmerkung: Andere Meinungen/Ergebnisse wurden bei korrekter rechtlicher Argumentation ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

Vgl. zum Ganzen BGE 137 I 209